

1500222-55.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... do caráter permanente do delito de tráfico de entorpecentes. Assim, fica repelida referida tese defensiva pelos motivos expostos alhures.

Neste sentido, aliás, forte a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500222-55.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500222-55.2021.8.26.0551

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

DIEGO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e estão sendo processado como incurso no art. 33, caput, art. 33, §1º, inciso I, e artigo 34, todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque, na data de 19 de maio de 2021, por volta de 17h00min, na Rua Seringueira, nº 510, Bairro Areias, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, e na Rua Nelson Cavaquinho, nº 83, na cidade e Comarca de Americana/SP, preparou, produziu, fabricou e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, uma porção menor e 24 porções maiores ("tijolos") de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "Maconha", pesando 20.251g, bem como 29 porções de "Cocaína", embaladas em forma de "tijolos", pesando 27.300g; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que na mesma data, hora e locais, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP e na cidade e Comarca de Americana/SP, DIEGO DE SOUZA preparava, produzia, fabricava e mantinha em depósito matérias-primas, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, tais como 205 kg de pó branco contendo Cafeína, 22 litros de Acetona e 40 litros de Acetato de Etila sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que na data de 19 de maio de 2021, por volta de 17h00min, na Rua Nelson Cavaquinho, nº 83, e na Rua Oscar Mendes, nº 131, ambos na cidade e Comarca de Americana/SP, DIEGO DE SOUZA adquiriu, utilizou, possuía e guardava instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, consistentes em 04 balanças digitais, 07 bacias plásticas, 02 peneiras, 01 dosador, 01 rolo de saco plástico, embalagens com sacos plásticos e balões, e 01 máquina de contar cédulas, todos apresentando resquícios de Cocaína³, bem como 01 secador, 02 peneiras, 01 forma de prensa com a inscrição LAMBADA e 01 forma de prensa com a figura ESTRELA, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, na data de 19 de maio de 2021, por volta de 17h10min, na Rua Nelson Cavaquinho, nº 83, na cidade e Comarca de Americana/SP, DIEGO DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma pistola marca Glock, calibre 9mm, nº RSS454, com 31 cartuchos íntegros do mesmo calibre.

O réu, devidamente notificado (fls. 335), apresentou, por meio de advogado constituído, defesa prévia (fls. 405/413). A denúncia foi recebida (fls. 427/431) e o réu citado pessoalmente (fls. 540). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas e uma informante arrolados pela defesa (fls. 413 e 570) e o acusado foi interrogado ao final.

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 732/748).

A defesa, por sua vez, em alegações finais, sustentou, em preliminares, máculas insanáveis na investigação, cerceamento de defesa, nulidade pela quebra da cadeia de custódia e pela violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição do réu com base na insuficiência probatória, e subsidiariamente, pela fixação de pena base no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado, bem como pelo direito de apelar da sentença em liberdade (fls. 756/778).

É o breve relatório.

DECIDO.

Primeiramente, necessária uma breve digressão acerca das audiências realizadas na modalidade virtual, por intermédio de tecnologia que viabiliza a promoção de reuniões por videoconferência, conforme procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Tratou-se de medida inicialmente destinada a contornar os impactos decorrentes do distanciamento social imposto pelo evento imprevisível trazido pela pandemia COVID19, que implicou na necessidade de se redimensionar os meios e instrumentos de colheita de provas nos processos judiciais, para compatibilizar, de um lado, a garantia da razoável duração do processo e adequada prestação jurisdicional, e de outro, a proteção à saúde pública.

Sabe-se que os momentos de crise demandam dos gestores a criação de soluções rápidas e eficazes, e no que diz respeito em específico à prática dos atos judiciais pela via remota, o resultado mostrou-se exitoso, com superação inclusive de tradicional resistência verificada no âmbito doutrinário, provando-se que o uso da tecnologia permite a realização dos atos com pleno respeito aos imperativos do devido processo legal e ampla defesa, com a vantagem de em muitos casos viabilizar a contenção de despesas com transporte e deslocamentos despendidos.

No caso em testilha, a prova oral foi colhida em âmbito remoto, com uso das ferramentas que permitiram a realização das reuniões por videoconferência, e o que se constata é o resultado plenamente satisfatório das audiências, coadunando-se de modo integral os propósitos de eficiência, legalidade, e respeito aos primados da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, considerando-se que todas as provas pertinentes e cabíveis ao caso foram produzidas, e que o processo encontra-se apto a pronto julgamento, passo à análise das questões preliminares suscitadas.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA.

Inicialmente, alega a nobre causídica que o direito de defesa do réu teria sido cerceado, em razão de somente ter sido acostado ao processo o teor da ordem de serviço que deu ensejo aos inícios das investigações, em data posterior ao oferecimento da defesa preliminar, a implicar na carência de paridade de armas entre acusação e defesa.

A despeito do quanto argumentado, a juntada do documento de fls. 434/437 em data posterior à apresentação da defesa preliminar não trouxe qualquer prejuízo ao acusado, seja porque tal documento não ostenta dados relevantes que pudessem alterar o desfecho do julgamento, seja porque as partes tiveram pleno acesso a ele em data muito anterior à primeira audiência de instrução.

Pelo que deflui do teor de referida ordem de serviço, a unidade especializada em repressão ao tráfico de drogas da capital (DENARC) recebeu informações acerca do prática de comércio ilícito na região de Americana/SP, por pessoa que ostentava determinadas características e conduzia veículos com placas parcialmente identificadas. A partir daí, munida com o mínimo de informações necessárias, a polícia judiciária deu início às investigações, emitindo, para tanto, referida ordem de serviço. Possivelmente, as informações previamente obtidas foram

fornecidas em caráter anônimo, sendo certo que em tempos de criminalidade organizada, onde vigora a "lei do silêncio", os chamados "disque denúncias" ostentam inegável relevo, sendo tal situação plenamente comum e regular, não havendo qualquer nulidade.

Portanto, as investigações foram iniciadas sem anormalidades, e não se verificou qualquer espécie de prejuízo à defesa.

No que tange ao suposto ingresso irregular em residência, em que pese o esforço da combativa defesa, face ao conjunto probatório não há que se falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, pois conforme restou demonstrado nos autos, os policiais adentraram nos imóveis somente após realizadas diversas diligências, campanhas com mapeamento das ações do acusado e dos imóveis utilizados, além de abordagem pessoal e veicular onde foram identificados compartimentos secretos para o armazenamento de drogas (fls. 740/742), e resquícios de maconha. Após colhidos tais elementos, municiados com fundadas razões, tiveram motivos para ingressar no primeiro imóvel, onde foram localizadas drogas em quantidade elevada, o que também tornou legítimo o ingresso nos outros imóveis e automóveis, onde foram localizadas imensa quantidade de entorpecentes, arma de fogo e insumos para o preparo e embalo de drogas.

Portanto, vigentes estavam as fundadas razões justificadoras do ingresso no domicílio, ante a patente situação de flagrância, uma das exceções à inviolabilidade constitucionalmente prevista. Evidentemente, o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não configura direito absoluto, notadamente dada a situação concreta de flagrante delito, especialmente em virtude do caráter permanente do delito de tráfico de entorpecentes. Assim, fica repelida referida tese defensiva pelos motivos expostos alhures.

Neste sentido, aliás, forte a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVASÃO DE DOMÍLIO – Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME – Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tanta a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021) (grifei)

Afirma ainda a defesa, por derradeiro, que não há nas provas colhidas e acostadas aos autos o adequado percurso traçado pelos agentes responsáveis pela investigação, circunstância que sugere a nulidade do procedimento, especialmente por implicar em violação aos predicados da ampla defesa e contraditório.

Pois bem, como é sabido, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, em vigor desde o dia 22 de janeiro de 2020, trouxe alterações significativas na legislação penal e processual penal, e dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal, com o seguinte teor:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

A norma tem como escopo regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

No presente caso, sustenta a douta defesa que (1) os imóveis e veículos onde foram localizadas as drogas, insumos e arma de fogo, não foram periciados; (2) o laudo de exame químico toxicológico de fls. 124/129 apresenta inconsistências; (3) houve transcurso de tempo inaceitável para a lavratura do flagrante; (4) a polícia científica não foi chamada a comparecer ao local; e, por derradeiro, (5) as drogas foram transportadas sem lacres.

Em primeiro lugar, cabe anotar que os horários constantes dos documentos nem sempre são precisos, mas o longo lapso temporal transcorrido entre a prisão do acusado e a lavratura do auto de prisão em flagrante decorreu da grande distância entre o local dos fatos e o endereço da delegacia de polícia especializada, localizada na capital, bem pelo fato de que houve apreensão de quantidade muito grande de drogas e outros produtos, sendo necessário o transporte cauteloso, ante o evidente risco envolvido. Portanto, consideradas as peculiaridades do caso, não se vislumbra situação excepcional que possa nulificar os elementos da prisão em flagrante.

No que diz respeito ao laudo pericial, o documento de fls. 124/129 é elucidativo em comprovar a enorme quantidade de entorpecentes mantida nos imóveis e veículos, e o fato de alguns itens não terem sido identificados decorre da grande variedade de insumos utilizados para o preparo dos entorpecentes para a venda, o que não resulta

em mácula na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, sendo que nesse aspecto, de rigor aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a invalidade se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a credibilidade da prova. Neste passo, no caso em tela, inexistente dado concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia num cenário a comprometer a confiabilidade da prova pericial, pois em detrimento de alguns poucos insumos não identificados, houve certeza e precisão quanto à existência de grande quantidade de drogas - maconha e cocaína - bem como cafeína, acetona, e acetato de etila.

No que atine à irresignação da defesa quanto à ausência de deslocamento imediato da polícia técnica ao local dos fatos, bem como ausência de inserção dos lacres nas drogas logo no momento em que apreendidas, de se observar que o inciso I do artigo 158-B do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer, como a primeira etapa da cadeia de custódia, o reconhecimento, isto é, o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Em se tratando do crime de tráfico de drogas, reputa-se evidente que o vestígio a ser preservado consiste no entorpecente localizado (e eventuais insumos a serem utilizados no preparo da droga para venda). Dessa forma, uma vez realizado o reconhecimento da droga como elemento relevante para a produção da prova e após a sua respectiva coleta, faz-se despendendo o isolamento da área, na medida em que a materialidade delitiva será aferida a partir da análise da substância ilícita, sendo irrelevante, portanto, a realização de perícia no local em que o entorpecente foi localizado, eis que desnecessário para fins de comprovação da prática delitiva. Em outras palavras, a movimentação da máquina policial para a realização da perícia no local dos fatos não se justifica no caso concreto, sendo tal providência dispendiosa e desnecessária, além de se revelar inócua, uma vez que a configuração do delito de tráfico de drogas se aperfeiçoa com a simples posse, guarda ou armazenamento do entorpecente, pouco importando o local em que tal conduta ocorreu.

Além disso, o artigo 158-C do Código de Processo Penal dispõe que a coleta dos vestígios deve ser feita preferencialmente por perito oficial, tratando-se, portanto, de uma recomendação, de modo que nada obsta que seja realizada por policiais ou outros agentes. Assim, não sendo o caso de isolar a área, consoante já demonstrado, evidente que não houve qualquer mácula na preservação da prova hábil a nulificar o procedimento.

Por tal razão, também não se verifica violação ao que consta do artigo 158-D, do Código de Processo Penal, que impõe sejam os vestígios submetidos a lacres em recipientes adequados, para que não ocorram violações ou vazamentos das substâncias. Embora a douta defesa sustente que os produtos apreendidos não teriam sido imediatamente lacrados, para, então, serem encaminhados ao distrito policial, o que poderia dar ensejo à indevida manipulação e interferência na cadeia de custódia, de se observar que tal providência não é necessariamente imprescindível, tudo a depender das circunstâncias em concreto. Evidentemente, os vestígios devem sempre ser transportados ao setor de perícias já com o devido lacre, para identificação e conferência de forma correta, de forma a inviabilizar a ocorrência de erro nos exames. No entanto, o momento da inserção de lacres pode variar, não havendo uma imposição rígida e incontornável, pois as ações policiais são marcadas pela aleatoriedade e imprevisibilidade de resultados. Na situação em tela, ao que tudo indica os policiais realizavam o monitoramento das ações do réu há vários dias, e não se sabia se e quando haveria a abordagem. Tampouco era sabido se eventual abordagem resultaria em prisão em flagrante. O estopim para a ação dependeu de circunstâncias aferíveis pelas regras de experiência, conveniência e

oportunidade (tirocínio). Não havia certeza quanto às consequências da ação, que de um lado poderia ser frustrada, de outro poderia resultar em flagrante de pequeno porte (quantidade de entorpecentes não volumosa), ou, ainda, poderiam implicar numa apreensão grandiosa (que é a hipótese dos autos, onde foi desbaratado um mini laboratório). Portanto, considerando-se que os resultados da ação policiais não eram previsíveis, não era mesmo de se exigir que os agentes estivessem munidos do aparato apropriado para imediato armazenamento dos produtos ilícitos, sendo plenamente justificável o seu transporte até a delegacia especializada, para que, então, fossem colocados nos recipientes, e finalmente lacrados.

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/23), laudo de constatação (fls. 24/31), laudo de exame químico toxicológico (fls. 124/129), laudo pericial em objetos e veículos apreendidos (fls. 173/176, 181/224, 551/559), laudo pericial de arma de fogo e munições (fls. 105/111) e pela prova testemunhal.

Cabe a análise da autoria, o que será realizado a seguir.

Ao ser interrogado em sede policial o acusado exerceu o direito ao silêncio. Em juízo, reservou-se ao direito de somente responder aos questionamentos da advogada de defesa, ocasião em que disse ter sido detido por volta de 17 horas e levaram cerca de 1 hora e 40 minutos para o levarem outros endereços. Foi levado para São Paulo às 3 horas da madrugada. Teve contato com advogado somente na hora do almoço. Não houve apoio da polícia militar ou da guarda. Os policiais chegaram dando tiros ao alto. Ouviu os policiais dizendo que não era para chamar a polícia militar ou a polícia civil local. Foi agredido por policiais. Foi algemado logo no início da ocorrência. As viaturas eram descaracterizadas. O proprietário não estava no local. Não apresentaram mandado de busca e apreensão. Não acompanhou o encontro das drogas. Não autorizou a entrada de ninguém. Possui cavalos no sítio há pelo menos 5 anos. Foi transportado para diversos locais. Viu que os policiais pararam em um local para pesar as drogas. Não sabe quem era o Delegado, pois não o viu. Não viu as drogas sendo lacradas. Tem um filho. As testemunhas da chácara Seringueiras não foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Não sabe se o proprietário foi intimado para depor.

Pelo que se depreende, embora o acusado tenha se limitado a responder os questionamentos da defesa, sem esclarecer propriamente se detinha alguma relação com as drogas encontradas, sugere que a ação policial tenha sido realizada de forma totalmente arbitrária, tendo sido torturado e vítima de uma "armação".

Respeitada a versão defensiva, entendo que as assertivas apresentadas pelo réu não se mostram consistentes, não havendo elementos indicativos de que os policiais do DENARC, departamento especializado da polícia civil na capital, teriam se deslocado a cidade do interior para monitorar os passos do réu e "plantar" uma armadilha de forma aleatória e desmotivada. Aliás, o fato de ter sido mobilizado um departamento especializado sem vínculos com o local dos fatos é circunstância que, ao contrário do sustentado, garante maior equidistância dos policiais, tornando fantasiosa e inverossímil a tese de que teria ocorrido perseguição imotivada à figura do acusado.

Ao que tudo indica, a atuação de policiais da capital foi motivada por informações obtidas anonimamente, e que vinculavam o acusado ao tráfico de drogas realizado no âmbito de organização criminosa de grande porte, o que certamente justifica a ausência de comunicação com a polícia local, sendo estratégia necessária para se evitar o vazamento de informações. Não há elementos que demonstrem ação violenta

dos policiais (supostos tiros), tampouco tortura.

Nesse aspecto, o policial civil Elcio Goncalves Sotello esclareceu que estava cumprindo uma ordem de serviço no sentido de acompanhar o veículo VW/Gol, cor prata, placas GCW-7I17, que seria responsável por transportar drogas em Americana e região, o qual era utilizado por "Gordão". Passou a monitorar os trajetos do automóvel, mapeando os endereços que o condutor estacionava e encontrava pessoas, monitorando o acusado Diego por aproximadamente dez dias. Asseverou que, na data dos fatos, o veículo entrou na chácara localizada na Rua Seringueira, 510, na cidade de Limeira, e, em seguida, o condutor deixou o local com um HR da marca Hyundai. Disse que, quando o Hyundai/HR retornou à chácara, ele e outra equipe abordaram o condutor DIEGO, mas nada de ilícito foi localizado em sua posse. Esclareceu que foi encontrado um compartimento secreto na caçamba do veículo, onde havia resquícios de Maconha. Narrou que no local estava também estacionado o carro VW/Gol, cor prata, placas GCW-7I17, no qual também foi localizado compartimento secreto contendo um tablete de Cocaína. Relatou que, então, passaram nos locais previamente mapeados, que eram frequentados pelo réu. Narrou que na Rua Nelson Cavaquinho, 83, já no município de Americana, situa-se um imóvel locado por DIEGO, onde foram encontrados dois veículos: outro Hyundai/HR com compartimento secreto contendo 23 "tijolos" de maconha e moldes para prensa; bem como um Fiat/Strada, também com compartimento secreto, que escondia 3 "tijolos" de Cocaína. Esclareceu que, no interior da residência, também foi localizada uma pistola da marca Glock, calibre nominal 9 mm, equipada com carregador prolongado e municiada com 30 cartuchos íntegros; bem como 25 "tijolos" de Cocaína, 4 porções de crack, 1 "tijolo" de Maconha e farta quantidade de insumos para preparação e mistura de Cocaína, algumas balanças de precisão e diversos utensílios destinados ao preparo de drogas. Também localizaram R\$ 22.600,00, em dinheiro. Contou que, em seguida, dirigiram-se para o imóvel da Rua Oscar Mendes, nº 131, em Americana, também locado por DIEGO, local que o acusado residia e onde foram encontrados uma máquina de contar cédulas de dinheiro, alguns celulares e um veículo VW/Golf, em cujo porta malas havia resquícios de drogas. Nos imóveis situados na Rua do Jacaré e Rua Sítio Judilena, 2632, o primeiro em Americana e o segundo em Arthur Nogueira, nada de ilícito foi encontrado. Acrescentou que no interior dos veículos VW/Gol e no primeiro veículo Hyundai/HR apreendidos na posse do acusado estavam os controles dos portões e as chaves de todos os locais que foram encontradas drogas e objetos acima descritos. O acusado teria acompanhado as diligências, e autorizado a entrada na residência. A prisão teria ocorrido em torno de 17:00hs, e somente saíram do município de Americana rumo à capital na madrugada, quase ao amanhecer. Os produtos foram transportados à delegacia sem lacre.

O policial civil Douglas Renato Suniga trouxe versão similar a de seu colega de equipe (Falcão 58), trazendo narrativa coincidente no tocante aos procedimentos de campanhas e abordagem. Afirmou que as chaves e controles dos imóveis estavam nos veículos apreendidos na posse do réu. Pontuou que em todos os lugares, o acusado apontou para a equipe as chaves e o controle, colaborando com as diligências, pelo grande número de chaves e controles apreendidos. Não foi solicitada perícia no local, pois o Delegado responsável pela investigação reputou desnecessário. Desconhecia o acusado de outras investigações.

O policial civil Marcus Ryan da Silva também apresentou versão coincidente com a dos demais policiais, ressaltou, no entanto, que ao contrário do que constou no depoimento prestado em delegacia, somente foi aos dois primeiros endereços, visando prestar apoio à equipe, não tendo participado das diligências prévias.

A testemunha Giovana Gonçalves Colombo, namorada do acusado, afirmou desconhecer o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Sabe que ele tem um filho. Já foi até o sítio da rua Seringueiras, que é uma área de lazer. Sabe que o pai do acusado se encontra doente. Não sabe qual a fonte de renda dele. Sabe que ele vendia cavalos. Gustavo de Nadai é filho do dono da chácara. Nunca viu o acusado usar

outro veículo sem ser GOL Branco.

A testemunha Gustavo Aparecido de Nadai, narrou que conhece o acusado há cerca de 8 anos. A chácara da Rua Seringueiras, Limeira, era do seu pai, e Diego cuidava dos cavalos. Havia 3 cavalos no local. Já viu o acusado com sua namorada no local. Diego comparecia na chácara quase todos os dias. Na época dos fatos, estavam duas pessoas no local. Soube que ouviram tiros no dia que o acusado foi preso.

A testemunha Rodrigo Simione, narrou que conhece o acusado há quase 3 anos. É médico veterinário e atende os cavalos que o acusado possui. A chácara fica na rua Seringueiras. O acusado tinha 4 cavalos. Já viu o acusado com o um Golf branco. Comparecia ao local cerca de 1 ou 2 vezes por semana. Sabe que atendia os cavalos próximo a balsa, sabe que ele não morava lá, mas comparecia muito. O acusado utilizava um Golf. Já viu o acusado com uma HR. Quem efetuava os pagamentos era o acusado, em espécie (dinheiro vivo).

Diante quadro configurado pela prova testemunhal colhida em audiência, a alegação da defesa a respeito da fragilidade das provas não merece guarida, não podendo ser descartada a robustez dos depoimentos dos policiais, que se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade, bem como as demais provas carreadas nos autos.

Como já consignado, houve apreensão de enorme quantidade de entorpecentes, bem como petrechos e insumos utilizados no fabrico e distribuição dos produtos ilícitos ao público consumidor, além de detectados compartimentos secretos em veículos, e apreendida uma arma de fogo, sendo comprovada a vinculação do réu com todos os vestígios da ação criminosa. As testemunhas de defesa, por outro lado, não trouxeram informações relevantes que pudessem trazer dúvidas aos elementos certos e precisos obtidos pelas características da prisão em flagrante.

Ademais, é de se consignar que são dignos de créditos os depoimentos dos investigadores, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque suas declarações na fase extrajudicial e judicial foram seguras e coerentes. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente os réus.

Neste cenário, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante.

Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, confira-se:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (Habeas Corpus 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que guardava, preparava e mantinha em depósito, para distribuição mediante lucro, elevada quantidade de drogas, insumos e petrechos,

além de arma de fogo.

Portanto, não há qualquer dúvida acerca da realização do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, consistente em preparar, produzir, fabricar e manter em depósito drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por outro lado, a acusação que pesa sobre o réu pelo crime previsto no artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06, não procede, aplicando-se à espécie, e consideradas as circunstâncias em concreto, o princípio da consunção.

Isso porque, embora os tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 33, parágrafo 1º, da Lei de Drogas, tenham objetos diversos, de um lado reprimindo-se a posse de drogas para fins de tráfico, e de outro, a posse de produtos químicos destinados ao preparo dos entorpecentes para venda, é certo e inquestionável que ambos os produtos – cocaína e maconha de um lado, cafeína, acetona e acetona de etila de outro - foram encontrados no mesmo local, em idêntico contexto, e a responsabilização pelas duas condutas implicaria em dupla punição pela prática de crime único, com resultado por demais rigoroso.

A corroborar:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS. DEFENSIVO. PRELIMINAR. Prova ilícita não caracterizada. Prescindibilidade de mandado judicial por se tratar de flagrante em crime permanente. Supostos vícios ocorridos na fase administrativa que não se projetam na ação penal. Nulidade do feito não configurada. Rejeição. MÉRITO. Absolvição quanto ao tráfico. Inviabilidade. Acervo probatório robusto que dá lastro à condenação. MINISTERIAL. Pretendida procedência quanto ao art. 33, § 1º, I. Impossibilidade. Ausência de materialidade. Ainda que assim não fosse, caracterizaria delito-meio, com aplicação do princípio da consunção. DOSIMETRIA. Penas intocadas. Inaplicabilidade das benesses da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º e do CP, art. 44. Regime fechado preservado. TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS. IMPROVIMENTO GERAL. (TJSP; Apelação Criminal 1500515-55.2020.8.26.0617; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) grifei

Nessa mesma linha de raciocínio, reputo atípica a conduta prevista no artigo 34 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que também é subsidiário ao delito de tráfico de entorpecentes. Não se pode dar interpretação extensiva ao tipo penal incriminador, vez que a posse e a manutenção de equipamentos, é figura a ser absorvida pelo crime de tráfico.

Sobre o tema, a seguinte decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal mostra-se elucidativa, e embora faça referência à legislação revogada, seus pressupostos permanecem íntegros:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E GUARDA DE MAQUINÁRIO E DE ESTOCAGEM DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADOS À MANUFATURA DE ENTORPECENTES (ARTS. 12, § 1º, I, e 13 DA LEI Nº 6.368/76, ATUALMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 33, § 1º, I, e 34, DA LEI Nº 11.343/06). CONDUTAS TÍPICAS QUE CONSTITUEM MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO DE DELITO DE ALCANCE MAIS AMPLO (FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio da consunção em relação aos crimes de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria prima destinados à manufatura de substâncias entorpecentes pode ser aplicado, uma vez que ditas condutas constituem meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, a fabricação de entorpecente. 2. Conclui-se que o intuito do legislador foi i) punir, por exemplo, o agente que constrói um laboratório para refino de cocaína, independentemente da sua efetiva produção,

ainda que a posse das máquinas e dos objetos em questão não seja, isoladamente, considerada ilícita (tais como, no caso em exame, de baldes e de um liquidificador); ou ii) sancionar aquele que mantém em depósito matéria-prima destinada ao refino ou à produção de drogas, mesmo que a estocagem dessa, por sua natureza, não constitua, per se, crime (no caso concreto, de solução de baterias, livremente revendida com fim específico de regeneração de cargas elétricas em baterias, e de barrilha, utilizada no tratamento de água para piscinas e para outras finalidades lícitas). 3. No caso em exame, pelo que se vê da denúncia, tanto a posse da matéria-prima, como a dos maquinismos/objetos, visava a um fato único: a produção de entorpecente (merla) pelo paciente naquele local, para posterior comercialização da droga. 4. Está patente nos autos a existência de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de fabricação. 5. Ordem concedida" (HC nº 100.946, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, por maioria, j. 25.10.2011.).

Portanto, evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, a procedência parcial da ação penal é a medida de rigor, merecendo, outrossim, a absolvição no que diz respeito à suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, e artigo 34, ambos da Lei de Drogas.

Resta inequívoca, outrossim, a configuração do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, pois a arma de fogo (pistola Glock com carregador para 31 munições) apreendida foi localizada no imóvel da Rua Nelson Cavaquinho, 83, Americana/SP, foi submetida à perícia e considerada plenamente eficaz e potencialmente lesiva (fls. 105/111). Não há dúvida de que o bem era mantido no local pelo réu, consideradas todas as observações realizadas no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

1. Do crime de tráfico de drogas

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, analiso, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere motivos do crime, suas conseqüências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade do agente, aos antecedentes, tem-se que o acusado é birreincidente (autos n. 002935-78.2014.8.26.0533 e 0004522-61.2012.8.26.0451), e portanto, é possível usar uma das condenações para a constatação de Maus Antecedentes, e outra para o reconhecimento da reincidência, sem que haja bis in idem.

No que se refere às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", é de se reconhecer que a altíssima quantidade de droga – quase 50 kilos – é hábil a abastecer inúmeras bocas de fumo da cidade de Americana, Limeira e arredores, e enseja a elevação da pena-base de forma considerável.

Desse modo, considerando-se os elementos analisados acima, fixo a pena-base do para o acusado em 10 (dez) anos de reclusão para cada e multa no valor de 1000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos

fatos.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante de reincidência para o réu, com aumento da pena em 1/6, fixando-as em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao delito de tráfico, incabível a aplicação da benesse contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 uma vez que o réu é duplamente reincidente.

No mais, as peculiaridades do caso demonstram que o réu nem de longe é um neófito no tráfico de drogas, do contrário não estaria assumindo a responsabilidade por manter e fabricar em torno de cinquenta kilos de drogas, nas variedades de maconha e cocaína, a serviço de evidente grupo organizado responsável pelo abastecimento de consideráveis pontos de venda nas regiões de Americana e Limeira, deixando clara a vinculação com organização criminosa e dedicação a atividades delituosas, o que também impossibilita a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do crime de posse ilegal de arma de fogo

Considerada a bi-reincidência do réu, possível utilizar uma das circunstâncias para fins de configuração dos maus antecedentes, e elevar a pena em 1/6 (esclarecendo que no crime de tráfico a pena foi duplicada, em virtude da enorme quantidade de drogas, circunstância que evidentemente não se aplica ao caso). Assim, fixo a pena -base em 1 ano e 2 meses de detenção, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, de se considerar a reincidência, a ensejar novo aumento de 1/6, fixando a pena em definitivo no patamar de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, e 12 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado DIEGO DE SOUZA, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Outrossim CONDENO o acusado DIEGO DE SOUZA às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03. Aplico a regra do artigo 69 do Código Penal (concurso de crimes).

De outra sorte, ABSOLVO o réu das imputações pela prática dos crimes previstos no artigo 33, §1º, inciso I e 34, ambos, da Lei n. 11343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e diante das penas aplicadas, o réu iniciará o cumprimento da pena relacionada ao tráfico de drogas no regime fechado.

Quanto à posse de arma, fixo o regime semiaberto, ante a reincidência.

Inviável a substituição das penas privativa de liberdade nos moldes do art. 44, do Código Penal.

Mantenho a prisão cautelar do réu, uma vez que não surgiram novos fatos ensejadores da revogação da custódia cautelar, além do que, evidente o risco à ordem pública, seja pela circunstância concreta do crime, que envolve gravíssima hipótese de tráfico em âmbito de organização criminosa de alto poder econômico, seja pelas notícias de reiterações praticadas pelo acusado (duplamente reincidente), a tornar

legítimo o receio de que a ordem pública seja afetada com a sua liberação.

Decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, especialmente a quantia em dinheiro e veículos (Hyundai/HR HDB, placas FRW-2G19, Hyundai/HR HDB, placas EAS-0943, Fiat Strada, placas FKQ-0625, VW Gol, placas CGW-7I17 e VW Golf, placas FTP-9F65), já que inequivocamente utilizados para a consecução do propósito criminoso.

Determino a destruição da droga apreendida.

Custas na forma da lei.

Limeira, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA